

1501936-92.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272200/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2272200 - 03º D.P. DIADEMA, 3479/21/127 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Wellington Lopes

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501936-92.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001451

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2272200/2021 - 03º D.P. DIADEMA, 2272200 - 03º D.P. DIADEMA, 3479/21/127 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Wellington Lopes

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

WELLINGTON LOPES, qualificado às fls. 04 e 13/14, está sendo processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 11h30, na Travessa Gonçalves Dias, situada na altura do nº. 395 da Rua Manoel Bandeira, no bairro do Campanário, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 49 embalagens contendo 28,4g da droga cocaína, 38 embalagens contendo 8,74g da droga cocaína, na forma de crack, e 119 embalagens contendo 206,6g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 09 e laudo de constatação provisória de fls. 10/12, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.33/35), o réu foi notificado e citado (fls. 105/106), e apresentou defesa preliminar as fls. 107/120, através do Advogado constituído, pugnando pela liberdade provisória e absolvição sumária, sem arrolar testemunhas diversas da Acusação. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 22/11/2021 (fls.150/151).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, concordando com a redução da pena, mas não também com sua substituição por restritiva de direitos, podendo ser fixado regime prisional mais brando.

Já o d. Advogado reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 09, nos autos de constatação e no definitivo (fls.10/12 e 95/97), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais civis (fls.2/3), estavam em diligências em um ponto já conhecido de comércio de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo com uma bolsa de pequeno porte em mãos. Assim que ele os avistou, apresentou um certo nervosismo e empreendeu fuga. Foram ao seu encalço, conseguindo alcança-lo alguns metros adiante. Abordado, realizaram uma busca pessoal, onde foi localizado no interior da pequena bolsa que o indivíduo portava, 119 porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, 38 porções de uma substância aparentando ser crack e 49 porções de uma substância aparentando ser cocaína. O indivíduo, qualificado como sendo Wellington Lopes, após ser indagado, confessou que há poucos dias estava realizando o comércio de entorpecentes no local, ganhando como remuneração uma porcentagem de suas vendas.

Sob o crivo do contraditório o policial Marcelo Rosseto esclareceu que estavam em diligências no local já conhecido como tráfico de entorpecentes. O réu estava com

uma bolsinha na mão, ele aparentou nervosismo e acelerou o passo, tentando fuga. Foi detido e em revista pessoal, dentro da pochete haviam porções de maconha, crack e cocaína. Questionado o que fazia no local, confessou que ia começar as vendas de droga. Reconhece o réu, e foi a primeira vez que o viu no local.

Igualmente o policial Wilson Brito recordou-se que realizavam diligências pelo local já conhecido como ponto de drogas. Avistaram o réu com uma bolsa na mão. Suspeitaram e decidiram aborda-lo. Assim que ele os viu tentou fuga, mas foi alcançado e abordado, e no interior da bolsa estavam as drogas. O réu confessou estar trabalhando no local há alguns dias e que acabara de receber as drogas para vender. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local. O réu, em solo policial (fl. 4) preferiu se manifestar apenas em juízo.

Em juízo o acusado confessou que estava vendendo drogas, e ao ver os policiais, ficou paralisado, tentou fugir porque estava desesperado, e precisando de dinheiro para pagar suas dívidas, estando arrependido. Não foi processado anteriormente.

Logo, a confissão judicial e a informal feita aos policiais não são provas únicas, pois vieram corroboradas pelos relatos uníssonos e harmônicos das testemunhas - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu confessou o crime nessa audiência una.

No mais, ressalto o Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento.

Não bastasse isso, os policiais sempre afirmara que o réu, por eles reconhecido, foi o indivíduo que correu saindo da biqueira, assim que percebeu suas presenças, e que era ele quem portava a bolsa com as drogas, e quem lhes confirmou informalmente estar traficando, ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, mas as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares de guardar e trazer consigo, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Afasto tese de estado de necessidade, pois os bens jurídicos são desproporcionais, por se colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade, em detrimento do interesse individual, além de se tratar de crime de perigo abstrato. Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade. Ressalto que o argumento de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena. Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão, que sequer foi provado pela Defesa. E lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Sobre o tema, já se decidiu: TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011). E mais, admitir a falta de emprego como causa excludente de ilicitude seria legalizar a prática de crimes por todo e qualquer indivíduo que esteja desempregado e em precárias condições econômicas - o que não é aceitável. (Processo nº 5004204-68.2020.8.24.0030 - TJ-PR).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (206 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (206 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado. Em segunda fase, ausente circunstâncias agravantes, mas presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), a reduzir a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, não podendo ir aquém disso, consoante Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. E quanto ao privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário, faz jus à benesse, mas em percentual menor dada à natureza de grande parte das drogas (cocaína e crack), de alto poder viciante e degradante do ser humano e da sociedade, tendo contribuído com organização criminosa, tanto que o próprio réu confirmou estar traficando há alguns dias naquela biqueira, o que demonstra sua maior dedicação à mercancia ilícita. Dito isso, opto pelo redutor de 3/5, a pena resta em 02 anos de reclusão mais 200 dias-multa.

A teor do disposto nos artigos 33, do Código Penal, fixo o regime prisional semiaberto, considerando a quantidade da pena, mas também a preponderância da natureza e da grande quantidade das drogas, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Neste sentido, vide: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade a conduta do traficante, dado que viola mais intensamente o bem jurídico tutelado, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de

pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido é o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra WELLINGTON LOPES, qualificado às fls. 04 e 13/14, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço

para condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

E o condeno, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesps, uma vez que não juntou declaração de hipossuficiência nem demonstrou minimamente sua situação de pobreza.

O réu não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).
Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA